

1001588-83.2018.8.26.0102

Classe: Reintegração / Manutenção de Posse

Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... não sabe se o imóvel foi utilizado para tráfico de drogas; o ponto de comércio foi construído, por completo, por FABIANO, após ele perder o emprego.

Em sua oitiva em juízo, o informante LEANDRO NOGUEIRA afirmou que: os Réus moraram muito tempo numa casa na CDHU, de MARIA APARECIDA; quando estava desempregado, FABIANO conversou com MARIA APARECIDA, pedindo para que ela emprestasse a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

Foro de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, Cachoeira Paulista - SP - cep 12630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1001588-83.2018.8.26.0102 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001588-83.2018.8.26.0102

Classe - Assunto

Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça

Requerente:

Maria Aparecida Wenceslau

Requerido:

Fabiano Benetti Cesar e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c perdas e danos proposta por MARIA APARECIDA WENCESLAU contra FABIANO BENETTI CÉSAR E ELISÂNGELA CRISTINA DE OLIVEIRA.

Narra a petição inicial que: comprovou-se, através do processo nº 3000017-19.2013.8.26.0102, que a requerente é proprietária e possuidora indireta de um imóvel localizado à Avenida Cunha, 240, bairro CDHU, nesta cidade e comarca de Cachoeira Paulista, motivo pelo qual o emprestou gratuitamente aos requeridos no ano de 2001, através de contrato de comodato verbal, por tempo indeterminado. Ocorre que, em 04/09/2018, a requerente promoveu uma notificação extrajudicial visando à rescisão necessária do comodato, com a consequente desocupação do imóvel por parte dos requeridos, o que não foi feito.

Assim, requer a autora, ainda liminarmente, que (i) seja expedido mandado de reintegração de posse do imóvel, (ii) condenando os requeridos ao pagamento das perdas e danos no valor de R\$1.000,00 (um mil reais) por mês, pelo período em que permanecerem – os réus – no referido imóvel.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 14/25.

Indeferido o pedido de justiça gratuita à parte autora (fl. 37).

A decisão de fls. 44/45 indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Devidamente citados, os Réus apresentaram a contestação às fls. 54/59, afirmando que: a) o imóvel foi adquirido por usucapião; b) houve um contrato verbal para

transferência dos direitos ligados ao imóvel, não comodato; c) tem direito à retenção pelas benfeitorias feitas, no valor de R\$40.000,00, mais o valor do fundo de comércio (R\$ 36.000,00) e as parcelas pagas à CDHU (R\$ 38.316,00).

A parte Autora apresentou réplica às fls. 104/107.

Deferidos os benefícios da justiça gratuita aos requeridos à fl. 132.

Requerimento de provas às fls. 112/125.

Decisão saneadora às fls. 139/141 deferindo a produção de provas testemunhal e depoimento pessoal postulada pelas partes.

Fora realizado um novo pedido de tutela antecipada às fls. 153/166, do qual os requeridos se manifestaram às fls. 170/175.

Termos de audiência (fl. 207).

Manifestação da parte requerida às fls. 208/277, apresentando documentações norteiam as informações relativas aos valores gastos com o imóvel e suas respectivas atualizações.

Alegações finais das partes às fls. 280/292 (requerente) e 296/303 (requeridos).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Passo a decidir e fundamentar.

Da usucapião e do efeito positivo da coisa julgada

O art. 502 do CPC/2015 assim define a coisa julgada material:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A coisa julgada material produz dois efeitos diferentes: a) o efeito negativo, que impede que a mesma demanda seja proposta novamente; b) o efeito positivo, que exige que, nos outros processos nos quais aquela relação jurídica seja discutida incidentalmente, decida-se em conformidade com o resolvido no processo original (que deu causa à coisa julgada).

Sobre a função positiva da coisa julgada:

“(...) a geração da função positiva da coisa julgada não ocorre na repetição de demandas em diferentes processos – campo para a aplicação da função negativa da coisa julgada -, mas em demandas diferentes,, nas quais, entretanto, existe uma realção jurídica que já foi decidida no primeiro processo e em razão disso está protegida pela coisa julgada. Em vez da teoria da tríplice identidade, aplica-se a teoria da identidade da relação jurídica.

Na função positiva da coisa julgada, portanto, inexiste obstáculo ao julgamento de mérito do segundo processo, mas nesse julgamento o juiz estará vinculado obrigatoriamente em sua fundamentação ao já resolvido em processo anterior e protegido pela coisa julgada material” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. Salvador: Editora Juspodivm. 10ª ed., 2018, p. 883) (grifos acrescentados)

Nota-se que, no processo de n. 3000017-19.2013.8.26.0102, decidiu-se que os Réus não adquiriram a propriedade do imóvel por usucapião.

Por consequência, em nome da eficácia positiva da coisa julgada, adoto, como premissa da presente decisão não houve aquisição da propriedade por usucapião em favor dos Réus, rejeitando, portanto, a tese suscitada na contestação.

Do contrato de comodato e da reintegração de posse

O art. 579 do CC/02 define o comodato como empréstimo gratuito de coisas não fungíveis:

Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.

Desde que respeitada a hipótese do art. 581 do CC/02, nos comodatos sem prazo determinado, é lícito ao comodante resolver o contrato unilateralmente, procedendo à retomada da coisa, na forma do art. 473 do CC/02:

Inventário. Decisão interlocutória que determina a imissão da inventariante na posse de bem imóvel no qual reside um dos herdeiros e sua esposa. Inconformismo.

Tese de que a retenção da posse do imóvel é legítima, vez que autorizada pelo autor da herança. Acolhimento parcial. Contrato de comodato verbal que comporta resilição unilateral (art. 473 do CPC), desde que haja notificação premonitória. Esbulho possessório não caracterizado. Plausibilidade do direito material suscitado. Ressarcimento de despesas pelo comodatário. Aplicabilidade do art. 584 do Código Civil. Indenizações restritas às despesas extraordinárias e urgentes que excedam os dispêndios necessários à conservação normal da coisa e que não resultam em direito de retenção para o comodatário. Incabível a retenção por benfeitorias do imóvel cedido em comodato gratuito. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2273681-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Rômulo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Chavantes - Vara Única; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020) (grifos acrescentados)

No caso concreto, a prova colhida em audiência convergiu para a realização de um comodato verbal, por meio da qual a parte Autora permitiu que os Réus, em momento de dificuldades, passassem a residir no imóvel, sem qualquer contraprestação (somente pagando o financiamento e as contas).

Em seu depoimento pessoal, a Autora MARIA APARECIDA WENCESLAU afirmou que: não propôs que o Réu pagasse as prestações atrasadas (não sabia nem que existiam prestações atrasadas); ela pagava as prestações atrasadas da CDHU; nunca residiu na residência, por questões familiares ligadas à mãe e à irmã; emprestou o imóvel para FABIANO quando ele estava passando por necessidades; requisitou a devolução da casa 5 vezes, desde 2009; não se lembra em que ano emprestou a casa; recebeu a casa do CDHU por volta do ano de 1992; os Réus entraram na casa uns 10 anos depois; propôs ao Réu que fosse morar na casa pagando as prestações da CDHU e as contas; nunca teve a pretensão de vender o imóvel; foi ela quem fez o ponto comercial (ia fazer uma padaria); ele fez o que quis na casa; nunca quis vender ou dar a casa; não sabia das obras feitas pelo Réu (ele 'foi fazendo'); foi a Autora quem começou a fazer o ponto comercial; depois, o Réu fez mais obras por conta dele.

Em seu depoimento pessoal, a Ré ELISÂNGELA CRISTINA DE OLIVEIRA afirmou que: à época dos fatos, a requerente emprestou a casa para eles, desde que eles pagassem as prestações e contas da casa, e depois a venderia, uma vez que não tinha pretensão de morar lá; quem fez a proposta inicial foi a própria requerente; FABIANO não quis mais residir na casa; nunca pagaram aluguel, apenas as prestações e contas; a Requerente emprestou a casa porque esta estava "abandonada"; poderiam ficar morando, pagando as contas; com o tempo, a casa seria vendida aos Réus; FABIANO não mora na casa atualmente; a Ré nunca pagou aluguel, só IPTU, prestação da casa, luz etc.; quando entraram na casa, a antiga moradora tinha deixado prestações em aberto; depois, foi feito um acordo com a CDHU; não sabe como foi feito esse acordo; desde quando entraram na casa, a Autora não pagou mais nada de prestações; não sabe de conversa de venda posterior da casa (só a conversa inicial); as prestações da CDHU estão pagas até maio/2022.

Em seu depoimento pessoal, o Réu FABIANO BENETTI CESAR afirmou que: a Autora emprestou o imóvel em 2001 porque ele estava passando por necessidades; o imóvel estava abandonado; a requerente afirmava que não tinha pretensões de se mudar para o imóvel, motivo pelo qual pretendia a venda; a proposta foi de ele reformar o local e morar lá, o que foi aceito; o local era usado por usuário de drogas antes dele se mudar para lá; a intenção da Autora foi sempre de vender o imóvel para ele; a conversa foi realizada na casa que Maria Aparecida residia na época; a relação dele com a requerente é apenas de parentesco, porque ela foi esposa de um tio; entrou com processo para aquisição da propriedade do imóvel, que foi julgado improcedente; não mora mais no imóvel, porque se separou de Elisângela (há cerca de 1 ano e 4 meses); o contrato foi verbal e decidiram não fazer documento formal e escrito porque "confiavam na palavra um do outro"; a Autora não gostava do local e reiterava que não queria a casa.

Em sua oitiva em juízo, a informante VALDERES MARIA PEREIRA afirmou que: em 1995, foi morar na CDHU; conheceu os Réus por volta de 2001, quando eles foram morar lá; antes de os Réus se mudarem, a casa era comum, não conservada (estava bem acabada),

parecida com as demais do CDHU; se lembra que, antes dos requeridos, morava um casal; depois disso, o casal saiu; depois, vieram os Réus; não conhece a requerente; os Réus comentavam que uma tia de FABIANO deixou que eles morassem lá desde que pagassem as prestações, contas e tributos da casa; os requeridos fizeram reformas na casa; os Réus nunca falaram que eram donos da casa, apenas que eles pagavam as prestações e demais contas referidas à casa; os Réus comentavam que, após os pagamentos das prestações, a tia de FABIANO (que emprestou a casa) tinha a intenção de vender a casa para eles, pois não queria mais morar lá; os Réus conviviam em família na casa e estabeleceram comércio (um bar aberto ao público); os Réus residem no local há cerca de 20 anos; não sabe se a Autora foi ao local pedir a devolução do imóvel; antes dos Réus, chegou a ver um casal morando lá; não sabe se o imóvel foi utilizado para tráfico de drogas; o ponto de comércio foi construído, por completo, por FABIANO, após ele perder o emprego. Em sua oitiva em juízo, o informante LEANDRO NOGUEIRA afirmou que: os Réus moraram muito tempo numa casa na CDHU, de MARIA APARECIDA; quando estava desempregado, FABIANO conversou com MARIA APARECIDA, pedindo para que ela emprestasse a casa e que, quando ele estivesse com a vida mais organizada, devolveria a casa; FABIANO morou lá por muito tempo; não soube de nenhuma conversa sobre algum acerto diferente do que o empréstimo da casa; estava presente no momento da conversa por meio da qual a Autora aceitou emprestar a casa; a Autora não falou em vender a casa a FABIANO no momento; os Réus não pagavam nada a título de aluguel; não sabe dizer quem residia no imóvel antes dos requerido; na época, não morava com MARIA APARECIDA, mas a conversa foi na casa dele; não sabe dizer de outras conversas entre as partes na época dos fatos; o empréstimo do imóvel não tinha data para a resolução; depois disso, acha que FABIANO conseguiu emprego; não sabe ao certo qual o emprego do requerido Fabiano, apenas acha que ele trabalha para a EDP; não tem conhecimento se a requerente pleiteou a devolução da casa; não frequentava o imóvel e não sabe dizer se Fabiano construiu benfeitorias, apenas sabe da existência do bar, porque quem começou a construção do ponto comercial foi a Maria Aparecida para construir uma padaria.

Em sua oitiva em juízo, a informante DORALICE BENETTI NOGUEIRA afirmou que: o imóvel é de Maria Aparecida e que ela emprestou a casa para os requeridos porque estes estavam passando por necessidades; essa conversa foi na casa da informante; o empréstimo seria até ele organizar a vida; não sabe de pretensão da requerente de vender a casa; não sabe de demais acertos entre as partes além do empréstimo do imóvel até que eles estivessem em melhores condições de vida; não sabe se a Autora chegou a pedir a casa de volta; não sabe de construção de benfeitorias pelo requerido, mas sabe que a requerente havia começado a construção de um "puxadinho" para abrir uma padaria; a conversa inicial foi feita em sua casa; não sabe porque a Autora não ia à casa, mas ela era uma pessoa ocupada, que cuidava da mãe e da irmã, tanto que não foi morar na casa; a relação das partes era boa, à época, não sabe hoje em dia; essa conversa faz muito tempo (bem mais de 10 anos – entre 10 e 20 anos); desde então, nunca devolveram a casa; há pouco tempo, FABIANO saiu da casa; a Ré continuou na casa; quando os requeridos entraram na casa, ela estava pronta, em condições de moradia; havia uma construção iniciada pela requerente para abrir a padaria, mas não sabe de eventuais benfeitorias feitas por FABIANO.

Em sua oitiva em juízo, a informante NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA afirmou que: é vizinha dos Réus; faz uns 20 anos que os requeridos residem lá; acha que a casa sempre foi bem cuidada; já morava lá quando os Réus chegaram; antes dos requeridos, a casa já era bem cuidada; antes dos Réus, morou um casal, sobrinhos de Maria Aparecida; depois, outro casal residiu lá (Alessandra, esposo e filhos); só depois, vieram os Réus; a Autora nunca morou lá; não sabe porque Maria Aparecida não residia no local; sabe que a Autora construiu muros e iniciou uma construção, inclusive com garagem e estrutura para alguma coisa; a Autora não deu a casa; na época dos fatos, a Autora ficou morando na residência do pai, cuidando da mãe; a Autora cedia a casa; Fabiano construiu um bar; não lembra de nenhum outro comércio antes; não tem conhecimento de pedidos para que os requeridos se retirassem da casa; voltou a morar na CDHU em 2006 (os Réus estavam lá); os Réus sempre moraram lá, nesses 20 últimos anos; não soube de nada ligado a pedidos de retomada de

imóvel; nunca ouviu comentários sobre isso; não pode dizer se eles se portavam como donos; sabe que a casa era da Autora; ninguém comentou que a casa tinha sido passada; não sabe se eles pagavam aluguel, se eles pediram a casa emprestada etc.; parece que a Ré vinha pagando o imóvel (não sabe há quanto tempo); os casais que residiram no local antes eram sobrinhos da Autora.

Em sua oitiva em juízo, a informante TATIANE CRISTINA FARIAS afirmou que: a Autora emprestou a casa porque o Réu estava passando por necessidades; depois, descobriram o processo do Réu contra a Autora porque viram que o nome da requerente estava "sujo"; não soube de intenções da requerente de vender ou dar a casa para os requeridos; não participou da reunião que decidiu o empréstimo, mas soube que houve o empréstimo num momento de dificuldade do Réu; não foi dito que a Autora venderia o imóvel; a requerente nunca residiu lá porque cuidava de sua mãe e de sua irmã, por necessidades de sua família (por ser muito longe, não tinha como cuidar dos familiares morando lá); a requerente queria abrir uma padaria, mas, pelas dificuldades familiares, não conseguiu se mudar; não sabe se a Autora pediu a casa de volta nos últimos tempos; sabe que, quando a Autora foi pedir a casa de volta, a avó do Réu estava morando lá; faz 6 anos que a avó não mora mais lá.

Por isso, conclui-se que: a) houve comodato verbal; b) a parte comodante notificou extrajudicialmente a parte comodatária (fls. 24/25).

Com a manifestação de vontade em prol da restituição da coisa emprestada, a posse do comodatário passa a ser injusta, uma vez que precária, na forma prevista no art. 1.200 do CC/02:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Sobre o conceito de posse precária, vale conferir a doutrina:

"b) Posse injusta é a que se instala no mundo fático por modo proibido e vicioso, ou então, mesmo iniciada de forma pacífica e pública, se converte em viciosa em momento posterior. Subdivide-se em três categorias:

(...)

b.3) posse precária: resulta do abuso de confiança do possuidor que indevidamente retém a coisa além do prazo avençado para o término da relação jurídica de direito real ou obrigacional que originou a posse. Inicialmente, o precarista era qualificado como titular de uma posse direta e justa, obtida através de negócio jurídico celebrado com o proprietário ou possuidor, conduzindo-se lícitamente perante a coisa. Todavia, unilateralmente delibera por manter o bem em seu poder, além do prazo normal de devolução, praticando verdadeira apropriação indébita" (FARIAS, Cristiano Chaves; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil: volume único. 4ª ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1.392/1.393) (grifos acrescidos)

Desta forma, está caracterizado o esbulho possessório, o que justifica a reintegração de posse pela parte comodante, como lhe garante o art. 1.210, caput, do CC/02:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Em casos semelhantes, o TJSP entendeu pela caracterização do esbulho possessório:

POSSESSÓRIA - Reintegração de posse - Ilegitimidade ativa afastada - Autora que é proprietária e possuidora do bem - Propriedade em condomínio que não exige a participação de todos os proprietários no polo ativo da ação - Comodato verbal configurado - Mera tolerância dos possuidores que não permite proteção possessória - Posse precária - Esbulho caracterizado a partir do pedido para desocupação - Permanência do requerido no imóvel, não obstante a solicitação de desocupação - Posse precária que não autoriza a proteção possessória - Indenização por perdas e danos mantida, pela ocupação graciosa no período entre a notificação e a efetiva desocupação - Sentença mantida - Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1002549-19.2020.8.26.0081; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 2ª Vara; Data

do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021) (grifos acrescidos)

Ação ordinária e ação de reintegração de posse c.c indenização por perdas e danos – Sentença de parcial procedência da ação ordinária e procedência da ação de reintegração de posse – Ebulho possessório caracterizado – Ocupação do imóvel pelo apelante a título de comodato verbal – Recusa em desocupar o imóvel – Notificação extrajudicial sem desocupação voluntária, a caracterizar o esbulho possessório do apelante – Requisitos do art. 561 do CPC e art. 1.210 do CC preenchidos, autorizando a reintegração da autora na posse do imóvel – Cabível a condenação ao pagamento de aluguel, por não desocupado o imóvel pelo comodatário, bem como indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel enquanto exerceu a posse – Realização de perícia para apurar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel e eventual locação – Insurgência em face dos valores – Descabimento – Laudo pericial apresenta parecer conclusivo, declinando todos os elementos que permitiram a apuração do valor devido, esclarecendo as técnicas empregadas para tanto – Mera insatisfação que não tem o condão de invalidar as conclusões do perito – Sentença mantida – Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal – Incidência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso negado.

(TJSP; Apelação Cível 1001736-06.2018.8.26.0099; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2021; Data de Registro: 01/12/2021) (grifos acrescidos)

Por isso, concluo pela caracterização do esbulho e pelo direito à reintegração de posse pela parte Autora.

Da acessão e do direito de retenção

Inicialmente, ressalte-se que os valores do fundo de comércio e aquilo pago para a CDHU não se caracterizam como benfeitorias, de sorte que não permitem a retenção (sem prejuízo de eventual demanda indenizatória, se o caso).

Já a construção do bar seria uma acessão.

Segundo o art. 1.248 do CC/02 a construção é uma forma de acessão, fazendo com o que o proprietário do terreno adquira a sua propriedade:

Art. 1.248. A acessão pode dar-se:

I - por formação de ilhas;

II - por aluvião;

III - por avulsão;

IV - por abandono de álveo;

V - por plantações ou construções.

No caso concreto, houve uma acessão, já que houve obras que, ao menos, completaram a construção de um bar/padaria no local.

Considerando que o possuidor de boa-fé tem direito à retenção pelas benfeitorias e necessárias, na forma do art. 1.219 do CC/02, o STJ tem precedente admitindo a retenção até a indenização pelas acessões:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR ACESSÃO E BENFEITORIAS. CONTRATO DE COMODATO MODAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE.

1. A teor do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em contrário.

2. No caso em apreço, há previsão contratual de que a comodatária abre mão do direito de ressarcimento ou retenção pela acessão e benfeitorias, não tendo as instâncias de cognição plena vislumbrado nenhum vício na vontade apto a afastar as cláusulas contratuais insertas na avença.

3. A atribuição de encargo ao comodatário, consistente na construção de casa de alvenaria, a fim de evitar a "favelização" do local, não desnatura o contrato de comodato modal.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1316895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 28/06/2013) (grifos acrescidos)

O TJSP também já se manifestou nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ENVOLVENDO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Decisão interlocutória que defere parcialmente pedido de tutela de urgência, autorizando a suspensão dos pagamentos do contrato, mas permitindo a imissão na posse da ré. Parcial reforma que se impõe. Realização de construção no lote, a admitir, em tese, a alegação de acessão artificial, e justificar o direito de retenção. O direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil, decorrente da realização de benfeitorias necessárias e úteis, também se aplica às acessões (construções e plantações) nas mesmas circunstâncias. Inteligência do Enunciado nº 81 do Conselho da Justiça Federal. Matéria que merece maior aprofundamento em fase instrutória, para o fim de se avaliar o cumprimento do art. 34 da Lei nº 6.766/79. Suspensão da imissão na posse, ademais, em razão da existência de vulnerabilidade dos agravantes, no contexto da Pandemia COVID-19, e nos termos da ADPF nº 828. Observação quanto à possibilidade de avaliação quanto à necessidade de pagamento de taxa de ocupação. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2125284-52.2021.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attiê; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2021; Data de Registro: 01/08/2021) (grifos acrescidos)

Havendo um real benefício na acessão àquele que retomará o imóvel, entendo que é possível o exercício do direito de retenção, já que está presente o mesmo motivo que justifica a retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias (proveito em favor de quem tem direito à posse).

Ao que parece, é o caso do presente processo, uma vez que a Autora já pretendia montar um negócio no local (padaria).

Assim, reconheço o direito à retenção pela acessão, de sorte que a retomada do bem somente ocorrerá após o pagamento dos valores ligados à construção do bar (só pela construção, sem qualquer análise sobre o exercício da atividade empresarial), como indenização pelas acessões, a ser apurado em posterior liquidação.

Da fixação de aluguel em favor da parte Autora

O art. 884 do CC/02 veda o enriquecimento sem causa, de sorte que ninguém faz jus ao recebimento de valores sem uma causa jurídica, devendo ressarcir valores recebidos dessa forma:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Por essa razão, não é possível tolerar que alguém se mantenha na posse de um imóvel, sem custos, quando o titular do direito à posse está privado do bem por conta dessa resistência ilícita.

Essa é a justificativa para o art. 582, parte final, do CC/02 que fixa o dever de o comodatário pagar aluguel durante o período em que resiste injustificadamente à desocupação:

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. (grifos acrescidos)

O TJSP reconhece o dever de pagar aluguel nesses casos:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. Demandante que pleiteia o arbitramento e a condenação do demandado no pagamento de alugueis pela ocupação de imóvel recebido por herança deixada por seu pai, cedido em comodato inicialmente ao demandado, que então padecia de crise financeira. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do demandado, que levanta preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de ilegitimidade ativa, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, aduzindo pedido subsidiário para o reconhecimento do direito de retenção em razão das benfeitorias inseridas no imóvel, além da natureza constitutiva da sentença. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Prova constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Ausência de impugnação específica pelo requerido em contestação, em relação ao valor indicado pela autora a título de aluguel. Circunstância que autorizava o indeferimento da pretendida prova pericial. Prova oral que era desnecessária, já que voltada à comprovação de benfeitorias, cujo direito a eventual ressarcimento pode ser discutido em Ação própria. Legitimidade ativa da autora bem configurada. Demandante que é proprietária do imóvel, conforme sentença proferida em Ação de Usucapião transitada em julgado. Alegação de nulidade na demanda declaratória que não comporta exame nesta Ação. Incontroversa ocupação do imóvel pertencente à autora pelo requerido que é incontroversa. Situação que justifica o arbitramento de alugueis. Entendimento contrário que implicaria autorizar enriquecimento sem causa do demandado, em detrimento da demandante, o que não se pode conceber, "ex vi" do artigo 884 do Código Civil. Pretendida retenção do imóvel que não comporta acolhida, mesmo porque o pedido inicial não abrangeu a restituição do bem. Alugueis que são devidos pelo demandado desde o recebimento da notificação extrajudicial, por consubstanciar a data de constituição dele em mora, "ex vi" do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1013513-35.2016.8.26.0009; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro: 24/11/2021) (grifos acrescidos)

POSSESSÓRIA - Ação de reintegração de posse - Imóvel - Contrato de comodato - Esbulho praticado pela ré evidenciado - Cabimento da fixação de alugueis pela ocupação indevida - Aplicação do art. 582 do Código Civil - Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1000850-58.2021.8.26.0048; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021) (grifos acrescidos)

No entanto, com o reconhecimento da licitude da retenção, seria incoerente obrigar que os Réus arquem com o aluguel quando exercem um direito (postura lícita, portanto).

Por isso, rejeito o pedido de pagamento de alugueis.

Dispositivo

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para determinar a reintegração da parte Autora no bem indicado na petição inicial.

Ato contínuo, reconheço o direito à retenção, de sorte que a retomada do bem somente ocorrerá após o pagamento da indenização pela construção do bar aos Réus, como indenização pelas benfeitorias / acessões.

A apuração do valor da construção do bar, sem qualquer análise sobre o exercício da atividade empresarial, deve ser apurado em posterior liquidação.

Condeno a parte Ré ao pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa diante da concessão da gratuidade de justiça aos Réus.

Após o trânsito em julgado e as certidões necessárias, dê-se baixa.

P.R.I.

Cachoeira Paulista, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA